

1502294-26.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... apreendidos, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502294-26.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502294-26.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e ambos os delitos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 30 de junho de 2022, por volta das 16h30min, na Avenida Irmã Dolores, em frente ao numeral 1, Jardim Quarentenário, neste município, associou-se ao adolescente R.S.M. para a prática reiterada de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar anteriormente descritas, trazia consigo, para fins de tráfico, 62 porções de maconha, 50 pinos contendo cocaína e 94 pedras de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticando tal conduta em concurso com o adolescente R.S.M., com quem foi apreendida uma mochila contendo 32 porções de maconha, 83 porções de cocaína e 51 pedras de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica. Foi

também apreendida com o acusado a quantia de R\$54,00.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia. A oitiva da testemunha arrolada pela Defesa não se realizou, pois a Defesa deixou de se manifestar quanto a não localização daquela, operando-se a preclusão. Ao final, foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência parcial da ação para condenação do réu quanto ao crime de tráfico de drogas e sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da natureza, da variedade e da quantidade de drogas apreendidas, o reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e o reconhecimento da causa de aumento de pena descrita na exordial. Requereu, outrossim, que não fosse aplicada a causa especial de diminuição de pena e a fixação do regime inicial fechado. Pediu, por fim, o perdimento da quantia apreendida.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Por fim, requereu a fixação de regime inicial diverso do fechado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação do §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, além da concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelas fotografias de fls. 33/39, pelos laudos de exame químico-toxicológico, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática dos crimes descritos na denúncia. Disse ser usuário de maconha e alegou ter ido ao local dos fatos, após sair de seu trabalho, para adquirir esse entorpecente. Contou que, no local, um policial, que não estava trajado como tal e não era nenhum dos depoentes, abordou-o e abordou o adolescente, indivíduo este que não conhecia. Disse que tinha em seu bolso R\$55,00, fruto de seu trabalho, e ainda não havia adquirido o entorpecente no momento da abordagem. Alegou que dois foram os policiais que realizaram a abordagem, mas eles não depuseram nos autos. Disse que outros adolescentes que estavam no local correram. Contou que não viu drogas sendo apreendidas.

Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida, além de não serem críveis, não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha policial civil André Luiz Luz, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, diante de notícia anterior acerca do tráfico de drogas no local dos fatos, área de mata ao final da Avenida Irmã Dolores e de difícil acesso, a viatura foi estacionada a certa distância e a incursão na região de mata foi realizada a pé. Disse que um transeunte informou, anonimamente, que havia dois indivíduos na área da mata, sendo que um deles portava uma sacola plástica e o outro uma mochila. Narrou que sua incursão se deu pelo final da Rua Jequié, enquanto seu parceiro deslocou-se pela Avenida Irmã Dolores, de forma a evitar a fuga de quem estivesse no local dos fatos e, então, ali foram surpreendidos o acusado e o adolescente R. Asseverou que o adolescente R. trazia consigo uma mochila, onde constatou haver diversos entorpecentes, e o acusado portava uma sacola plástica verde que continha cerca de R\$54,00 em dinheiro, além de mais de 200 porções de entorpecentes.

Consignou que o réu e o adolescente estavam lado a lado quando abordados e não houve tempo para que ambos fugissem. Declarou que, no local dos fatos, o acusado, informalmente, disse que somente não empreendeu fuga em razão do armamento estar próximo a ele e, em solo policial, admitiu que estava realizando o tráfico de drogas em razão de necessidade financeira, sem fornecer maiores detalhes. Narrou que o adolescente também confirmou estar praticando o tráfico de drogas no local.

Relatou que não havia outras pessoas no local da abordagem. Disse que não foi visualizado o ato de mercancia e não foram encontrados elementos que indicassem a associação prévia entre o acusado e do adolescente. Não havia visto o réu ou o adolescente no local anteriormente aos fatos. Esclareceu que não estava com o distintivo policial à mostra, mas, possivelmente, o indivíduo que anonimamente forneceu a informação à equipe percebeu, pelas características, ser policial. No mesmo sentido, a testemunha policial civil Carlos Rocha, também ouvida em Juízo, narrou que, com seu parceiro de ofício e em viatura descaracterizada, foi ao local dos fatos, em área de mata ao final da Avenida Irmã Dolores, em razão do qual já possuíam informação anterior sobre a ocorrência do tráfico de drogas. Consignou que, antes da incursão que realizariam, um transeunte não identificado informou que havia duas pessoas realizando o tráfico na área da mata. Relatou que ingressou naquela região pela avenida principal enquanto seu parceiro incursionou pela Rua Jequié, e ambos surpreenderam o acusado e o adolescente, que não conseguiram reagir e foram abordados. Afirmou que, com o adolescente, foi apreendida uma mochila contendo drogas e, na sacola plástica que o réu portava, foram localizadas porções de entorpecentes, além de pequena quantia em dinheiro, sendo que toda a droga encontrada totalizava mais de 300 porções. Relatou que não havia ninguém próximo ao local dos fatos quando da abordagem e da localização das drogas. Declarou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos e não foi apurado se o acusado e o adolescente estavam previamente associados para a prática do crime. Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas. Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a diligência ao local dos fatos, a abordagem do réu e a apreensão das drogas com ele e com o adolescente.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em

juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção

de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido

nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Mister se faz destacar-se que a denúncia descreveu os fatos relativos ao réu, possibilitando, assim, o irrestrito exercício da ampla defesa.

Outrossim, os fatos relacionados ao crime de tráfico de drogas, na forma como narrados na denúncia, foram integralmente demonstrados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação policial, a abordagem do acusado e a localização dos entorpecentes com ele e com o adolescente com quem praticava o crime, e encontram-se em verdadeira consonância com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

Ao contrário do alegado pela Defesa, as testemunhas, de forma uníssona, esclareceram como se deu a diligência no local dos fatos e descreveram, pormenorizadamente, o que puderam visualizar e o que localizaram tanto em posse do réu como em posse do adolescente.

Asseveraram que, feita a abordagem, na sacola portata pelo réu, foi localizada grande quantidade de drogas variadas e dinheiro, afirmando, ainda, que, na mochila portata pelo adolescente, havia também entorpecentes.

Veja-se, ainda, que os policiais ressaltaram que já havia notícia anterior acerca do tráfico de drogas realizado no local onde o acusado e o adolescente foram abordados.

O esforço da Defesa em desqualificar o depoimento das testemunhas policiais civis não é suficiente para retirar a força probante deles.

Dessa forma, não há dúvidas de que era o acusado o indivíduo que estava na posse da sacola em cujo interior foi localizada grande quantidade de drogas e que com ele estava o adolescente R, que também portava uma mochila contendo mais entorpecentes, não havendo qualquer dúvidas, portanto, sobre o tráfico de drogas realizado pelo réu.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Assim, a negativa do réu e a versão por ele apresentada - de que somente estaria no local dos fatos para adquirir drogas e que os policiais que o abordaram sequer eram os policiais depoentes - não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Frise-se que o teor do interrogatório judicial do acusado nem mesmo está em conformidade com sua versão apresentada à Autoridade Policial, momento em que confessou a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo que estava junto ao adolescente R. no local dos fatos.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se aos depoimentos dos policiais civis encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos policiais, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da variedade e da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da variedade e da quantidade de drogas e demais circunstâncias em que estas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310). A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 também restou demonstrada.

Conforme se observa dos autos, especialmente pelos seguros e harmônicos depoimentos das testemunhas policiais, ao lado do acusado foi também abordado o adolescente R., com quem foi apreendida uma mochila contendo drogas.

Dessa forma, restou devidamente demonstrado que o acusado, em concurso com o adolescente, estava praticando o crime de tráfico de drogas, havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar que a prática do crime envolveu o adolescente. Portanto, restou bem caracterizada a causa de aumento descrita na denúncia.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe.

De outro lado, quanto ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, não há prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório que possa embasar um decreto condenatório.

Não restou demonstrado que o réu efetivamente estava associado com o adolescente R., organizando-se previamente para a prática do delito de tráfico de drogas. Não há demonstração suficiente do pacto associativo entre eles.

Portanto, não há prova suficiente sobre o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo ser o acusado absolvido desta imputação, pois, como se sabe, a dúvida sempre deve ser resolvida em favor do réu.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se o aumento da pena. Assim, fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 1/6, ficando ela estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, fixando-se a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 40 inciso VI da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6, totalizando em 07

(sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

De outro lado, não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da grande quantidade da droga apreendida. Não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Ademais, a grande quantidade, além da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei) Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita de ter praticado o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social.

Destaca-se, ainda, a variedade e a natureza, além da grande quantidade dos entorpecentes apreendidos com o acusado, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, verifico presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 14 de outubro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA